

1006322-24.2022.8.26.0624

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: LIGIA CRISTINA BERARDI MACHADO

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - FURTO DE TELEFONE CELULAR - EMPRÉSTIMO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E PAGAMENTO REALIZADOS POR FRAUDADOR - BANCO QUE AFIRMA O FORNECIMENTO DE DADOS A TERCEIROS UMA VEZ QUE A OPERAÇÃO OCORREU MEDIANTE DIGITAÇÃO DE SENHA E INFORMAÇÃO DO DISPOSITIVO TOKEN - TESE DA INFALIBILIDADE DO SISTEMA DESCARTADA - SÚMULA Nº 479/STJ - DANOS MORAIS - SITUAÇÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

3ª Vara Cível

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Tatuí - SP - cep 18278-440

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1006322-24.2022.8.26.0624 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1006322-24.2022.8.26.0624

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Gregorio Pascoli Neto

Requerido:

Banco Bradesco S.a

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LIGIA CRISTINA BERARDI MACHADO

Vistos.

Gregorio Pascoli Neto ingressou com ação de declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela antecipada em face de Banco Bradesco S.A. Requer tutela de urgência para que o requerido se abstenha/suspenda qualquer cobrança, débito de parcelas de empréstimos pessoais relativas às operações realizadas de forma fraudulenta em seu nome no dia 29 de junho de 2022 (empréstimo pessoal 3069266, no valor de R\$ 406,88; empréstimo pessoal 3069408, no valor de R\$ 890,00; empréstimo pessoal 3070037, no valor de R\$ 880,00; empréstimo pessoal 3085345, no valor de R\$ 7.563,12), sob pena de multa diária de R\$ 1000,00 para o caso de descumprimento. Aduz, para tanto, não ter contratado nenhum tipo de serviço da requerida, bem como não autorizou os descontos em sua conta. Ao final requer a declaração da nulidade dos contratos de empréstimos pessoais tomados em nome do autor; declaração da inexistência do contrato; condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, custas e despesas processuais (fls. 01/27).

Em decisão de fls. 140/141 foram indeferidos os benefícios da justiça gratuita, e foi deferida a tutela de urgência.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação (fls. 153/163). Preliminarmente, pugnou pela revogação do deferimento do pedido de concessão da tutela e pela ausência de legitimidade passiva. No mérito, sustentou que a situação ocorrida foi alheia ao banco, tendo este agido apenas como agente financeiro, não podendo responder pela suposta fraude, que ocorreu fora da agência bancária, que as operações foram realizadas com o uso de chave de segurança constante no celular da parte autora, que foram realizadas a contratação de empréstimos pessoais, os quais foram realizados através de senha da conta corrente e chave de segurança ou token de conhecimento único da parte autora, através do MOBILE BANK, não havendo então contrato físico, e que o contrato questionado fora realizado a pedido da parte autora, ou de alguém que tinha acesso aos seus dados, aceitando ela todas as suas condições. Argumentou que as transações realizadas nos canais digitais são seguras, que não haveria o que se falar em transação anormal, já que os empréstimos e as transações não teriam sido realizados em valores maiores que as médias das movimentações da parte autora, não havendo suspeita de fraude, e que não haveria falha na prestação de serviços ou na segurança, por parte da ré. Afirmou ainda que, estaria presente o caso de fortuito externo, e que um sequestro não estaria ligado ao risco assumido pela execução da atividade bancária. Impugnou a inversão do ônus da prova, o pedido de danos moras, mas caso este procedesse, deveria ser levado em consideração o princípio da proporcionalidade. Postulou pelo acolhimento das preliminares arguidas, e no mérito, pela improcedência dos pedidos. Documentos anexados às fls. 164/248.

Réplica às fls. 253/261.

É o relatório.
DECIDO.

O feito comporta o julgamento antecipado da lide, tal como dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois as questões suscitadas e controvertidas nos autos constituem matéria desnecessária de produção de provas em audiência, bem como prova pericial, motivo pelo qual conheço diretamente do pedido.

A preliminar suscitada pelo réu, acerca da ausência de sua legitimidade passiva deve ser afastada, isso porque os valores solicitados por meio de empréstimo e os retirados da conta bancária da autora foram fornecidos pelo réu e também se encontravam sob sua guarda, sendo transferidos para terceiros, além de ter ocorrido por meio de aplicativo disponibilizado pelo réu.

Logo, é certo que o réu se mostra legítimo para figurar no polo passivo da presente demanda. Superada tal questão, passa-se ao mérito da causa.

A ação é procedente em parte.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, proposta pela requerente em face do banco réu, em razão de empréstimos indevidos em sua conta bancária.

Sustenta o requerido que inexistem indícios de falha no sistema de segurança bancário, tampouco nos serviços prestados sendo, na verdade, a entrega do celular por parte do autor crucial para a consumação da fraude praticada por terceiro estranho à lide. Assim como não haveria responsabilidade por operações financeiras realizadas através do uso de senhas pessoais e intransferíveis.

Contudo, nota-se que sem razão as alegações apresentados pelo requerido, isso por duas razões.

A primeira, porque a autora comunicou o ocorrido ao requerido de forma que registrou uma contestação de débitos não reconhecidos em sua conta de depósito (fl. 95), bem como lavrou Boletim de Ocorrência (fls. 93/95), razão pela qual ele poderia ter tomado as providências necessárias para bloquear/suspender as transações feitas.

E, a segunda, porque tais transações destoam do perfil da autora, razão pela qual o requerido faltou com o dever de cuidado ao autorizá-las.

Ademais, insta ressaltar que a responsabilidade da prestadora de serviços aos consumidores é objetiva, nos termos do artigo 14, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Súmula 297 “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” (STJ).

Nessa toada, a teoria sob a qual a atuação da instituição bancária deve ser analisada é, portanto, a teoria da responsabilidade objetiva, que, embora independa de culpa, bastando o fato danoso, exige como pressuposto à responsabilização, o nexo causal.

Para mais, a regularidade das transações discutidas nos autos não foi comprovada pelo réu, tratando-se de fato impeditivo do direito da autora (art. 373, inc. II, CPC).

Assim, não tendo sido realizado pela parte autora as transações discutidas, dever do banco réu declarar a inexigibilidade do débito efetuado mediante fraude.

Sobre o tema, a Egrégia Corte Paulista:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MOVIMENTAÇÕES EM CONTA CORRENTE NÃO RECONHECIDAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - FURTO DE TELEFONE CELULAR - EMPRÉSTIMO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E PAGAMENTO REALIZADOS POR FRAUDADOR - BANCO QUE AFIRMA O FORNECIMENTO DE DADOS A TERCEIROS UMA VEZ QUE A OPERAÇÃO OCORREU MEDIANTE DIGITAÇÃO DE SENHA E INFORMAÇÃO DO DISPOSITIVO TOKEN - TESE DA INFALIBILIDADE DO SISTEMA DESCARTADA - SÚMULA Nº 479/STJ - DANOS MORAIS - SITUAÇÃO QUE PODERIA CARACTERIZAR SIMPLES ABORRECIMENTO COTIDIANO - NEGATIVA DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PROCUROU SOLUCIONAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - MAXIMIZAÇÃO DO SOFRIMENTO E ANGÚSTIA DA CONSUMIDORA - ELEVAÇÃO DO DANO A PATAMAR INDENIZÁVEL - REPARAÇÃO REDUZIDA PARA R\$ 10.000,00, VALOR QUE BEM EQUACIONA O ABALO SOFRIDO, O CARÁTER PEDAGÓGICO E A VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, ATENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - SÚMULA Nº 326/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009314-02.2018.8.26.0008; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018).

RESPONSABILIDADE CIVIL Danos materiais e morais Fraude no sistema "internet banking" - Banco que responde não só pela segurança das ferramentas disponibilizadas em ambiente virtual, bem como pelo sigilo das informações pessoais de seus clientes Aplicação da Súmula 479 do STJ Excludente de responsabilidade não

comprovada Danos materiais devidos - Danos morais não configurados Ação de ressarcimento de danos materiais e morais parcialmente procedente Apelação provida em parte. (TJSP; Apelação Cível 1049089-03.2017.8.26.0576; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2018; Data de Registro: 13/12/2018).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transferência de valores por meio de aplicativo de celular não reconhecida pela parte autora. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Atuação de terceiro fraudador que restou incontroversa. Ônus da prova carreado à parte ré, que não demonstrou ter a parte autora agido com desídia em relação a seus dados pessoais. Culpa exclusiva da vítima não configurada. Responsabilidade objetiva. Aplicação do art.14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Dano material que deve ser ressarcido. Falha na prestação de serviço. Retirada de valores de poupança, cujo saldo foi zerado. Dano moral igualmente configurado. 'Quantum' indenizatório dos danos morais reduzido para R\$5.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e precedentes desta Câmara. Honorários recursais que não se aplicam, 'in casu', ante o acolhimento em parte do recurso. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1002803-88.2017.8.26.0568; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 22/10/2018).

Ato contínuo, notório que a alegação de fato de fortuito externo ou culpa do consumidor não merece prosperar, isso porque a contratação por fraudador de serviços ou aquisição de produtos fornecidos pela instituição financeira ré em nome da autora configura verdadeiro defeito na prestação de serviços ao consumidor.

Ademais, cuida-se de risco da atividade, conforme estabelece o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, in verbis:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

"Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

Sob outro aspecto, a culpa do consumidor capaz de excluir a responsabilidade do fornecedor de serviços é qualificada como exclusiva, nos termos do § 3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor: "(...)§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No entanto, não há que se falar em culpa exclusiva na hipótese em que o próprio fornecedor, por incompetência ou precariedade nos sistemas de segurança, fornece serviços ou entrega produtos não contratados pelo consumidor.

Somente o fortuito externo, ou força maior, é que exoneraria o devedor, mas exigiria fato externo, que não se liga à pessoa ou empresa por nenhum laço de conexidade (Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências, São Paulo: Saraiva, 1949, p. 291).

Desse modo, os empréstimos realizados pela parte autora não reconhecidos devem ser declarados inexigíveis.

Dessa forma, por todos os ângulos, a única vítima inocente é a parte autora.

O pedido de danos morais prospera.

Neste particular, são esclarecedoras as palavras do Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, vejamos: "Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Programa de Responsabilidade Civil. ed. 8ª São Paulo: Atlas, p. 83/84).

Ora, a conduta ilícita (art. 186, CC) invasora da intimidade da pessoa humana, atentando contra seu sigilo bancário, desassossegando o seu coração pela rapina de seu salário ou benefício gera, inegavelmente, transtornos que transbordam da normalidade, na medida em que nenhuma relação jurídica há entre as partes que autorize uma a apropriar-se de valores da outra ou deles dispor em favor de criminosos.

É indisputável o dever de indenizar os danos morais, sendo hipótese de dano in re ipsa.

Sobre o tema, confira-se:

"RESPONSABILIDADE CIVIL - BANCO - CARTÃO MAGNÉTICO - SAQUE INDEVIDO - DEFEITO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CASO EM QUE INCUMBIA AO RÉU O ÔNUS DE PROVAR A CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA OU DE TERCEIRO - RISCO DA ATIVIDADE QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDA AO CONSUMIDOR - REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL E MORAL CABÍVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO." (TJSP; Apelação Sumaríssima 9259950-22.2008.8.26.0000; Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª VC F Reg Penha de Franca; Data do Julgamento: 16/07/2008; Data de Registro: 29/07/2008).

Dessa forma, resta apenas fixar o quantum debeatur.

A propósito do arbitramento da indenização, deve o magistrado pautar-se em um papel compensatório para a vítima e, ao mesmo tempo, desestimulante ao ofensor (ou seja, o causador do dano deve ser apenado com um importe que o faça pensar antes de repetir a conduta).

Embora a Teoria do Desestímulo não seja expressa no Código Civil, existe projeto de reforma legislativa para acrescentá-la ao artigo 944 do Código Civil.

Em que pese a omissão legislativa, a doutrina não diverge sobre a dupla função da indenização moral.

De fato, tem-se decidido que, para a fixação do montante da indenização, devem ser levados em conta os seguintes parâmetros: "A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida; de modo que tampouco signifique enriquecimento despropositado da vítima; mas está também em produzir no agressor, impacto bastante para persuadi-lo a não perpetrar novo atentado. Trata-se então, de uma estimativa prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da alegria ou para os estados d'alma humana, e que, destarte, deve ser feita pelo mesmo Juiz, ou, quando não, por outro jurista - inútil por em ação a calculadora do técnico em contas ou em economia. É nesta direção que o citado Brebbia, em sua excelente monografia, aponta elementos a serem levados em conta na fixação da paga: a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima (situação familiar, social e reputação), gravidade da falta e da culpa,

que repercutem na gravidade da lesão e a personalidade (condições) do autor do ilícito" (Essa Inexplicável Indenização por Dano Moral, Des. Walter Moraes, Repertório IOB de Jurisprudência, nº 23/89, p. 417).

Procedendo à convergência dos caracteres consubstanciadores da reparação pelo dano moral, quais sejam: i) punitivo e profilático, para que as causadoras do dano, pelo fato da condenação, sejam castigadas pela ofensa perpetrada, bem assim intimidadas a se conduzirem de forma diligente no exercício de seu mister; e ii) compensatório, para que a vítima receba uma soma de dinheiro que lhe proporcione prazeres como contrapartida pelo mal sofrido, o valor da indenização deve ser fixado em R\$ 8.000,00.

Salienta-se que o valor adotado leva em conta a profissão da autora, o montante movimentado em sua conta, e a grave desídia do réu que, detendo todos os mecanismos para impedir a ocorrência das transações fraudulentas, não reconheceu a falha em seu sistema.

Anote-se que o valor pleiteado pela parte em sua petição inicial é meramente sugestivo, não implicando o seu acolhimento em montante inferior em sucumbência recíproca.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 326: "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca." (Corte Especial, julgado em 22/05/2006, DJ 07/06/2006 p. 240).

A correção monetária deve incidir desde a data desta decisão, na forma do verbete nº 362, das Súmulas de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 362: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." (Corte Especial, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008).

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: i) DECLARAR inexigíveis as transações não reconhecidas pela parte autora, tratando-se dos empréstimos realizados em 29 de junho de 2022 (empréstimo pessoal 3069266, no valor de R\$ 406,88; empréstimo pessoal 3069408, no valor de R\$ 890,00; empréstimo pessoal 3070037, no valor de R\$ 880,00; empréstimo pessoal 3085345, no valor de R\$ 7.563,12) e ii) CONDENAR o réu a pagar à autora indenização por danos morais consistente em R\$ 8.000,00, com correção monetária pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da data de publicação desta sentença (Súmula 362, STJ), acrescida de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, CC c/c art. 161, §1º, CTN), desde a citação (art. 405 CC e 240, CPC).

Dada a sucumbência, arcará o réu com as custas e despesas processuais (art. 82, §2º, CPC), além de honorários advocatícios, desde já fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C.

Tatui, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA